

1500052-28.2021.8.26.0246

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo(a)(s) Sr(a)(s). Fabricio Rodrigues Dias Silva

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500052-28.2021.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-28.2021.8.26.0246

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036990/2021 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 16120825 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 187/21/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2036990 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABRICIO RODRIGUES DIAS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra Fabricio Rodrigues Dias Silva.

Na denúncia, narra-se que no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 19h20min, na Avenida Quinze de Outubro, nº 370, apartamento nº 07, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, o réu, qualificado às fls. 05, guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 02 (duas) pedras da substância entorpecente popularmente conhecida como "crack", com peso total aproximado de 10g (dez gramas).

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 85/89). Posteriormente, foi deferida liberdade provisória (fl. 124).

Os laudos de constatação provisória e definitiva tiveram resultado positivo para crack (fls. 16/17 e 234/236).

Notificado pessoalmente (fls. 256), o réu ofereceu defesa escrita (fls. 262/264).

Recebida a denúncia em 17/12/2021 (fls. 265/266).

No curso da instrução (fl. 289) , realizou-se oitiva em audiência de duas testemunhas e do réu
Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa pela absolvição ante a ausência de provas.
Folha de Antecedentes Penais (fls. 37/38 e 268/269) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 39/40 e 270/271).
É o relatório.
Decido.

II -FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar de Nulidade por Invasão de Domicílio

Não há se falar em violação do domicílio e nulidade da prova obtida.

No RE 603616, Tema 280 da Repercussão Geral, o STF, em decisão paradigmática, estabeleceu:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) (destaquei)

A jurisprudência do STJ tem extraído do acórdão paradigma que: (i) "(0) ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 671.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021); e (ii) "(A) fere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou

não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência" (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No presente caso, as provas produzidas dão conta de que os policiais, após receberem denúncia anônima (fl. 27) – donde a fundada suspeita – abordaram o réu na rua, momento em que confessou o depósito de drogas em seu domicílio, franqueando nele a entrada.

Confessou para os policiais, pois provido de consciência. E a consciência, diante da flagrância, quer expiar a culpa que sobre ela recai: mecanismo psíquico de auto-preservação moral.

Tem-se, pois, que a entrada no domicílio não foi fundada somente na denúncia anônima, mas na confissão feita pelo réu aos policiais, seguida da autorização para que adentrassem a sua casa.

Dizer que a confissão frente aos policiais não é válida diante de suposto temor que se sente perante a autoridade nada mais traduz do que hipótese, dependente de prova empírica, a qual não foi feita.

Nem há nos autos evidências – para além da palavra do réu – de que os policiais tenham o constrangido de qualquer forma.

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente:

"- A condenação do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes não se fundou, exclusivamente, em denúncia anônima, mas nas circunstâncias do flagrante, na sua confissão extrajudicial, relatada pelos flagranteantes, e nos depoimentos dos agentes policiais condutores da prisão, confirmados em juízo. De fato, consignou-se que os policiais encontraram, em terreno abandonado, por indicação do próprio agravante, que confessou a prática do delito para os agentes, grande quantidade de material entorpecente acondicionado para venda, cuja origem também foi informada pelo flagranteado, bem como localizaram uma balança de precisão.

- Não estando a condenação do agravante escudada apenas em delação de pessoa não identificada, como se percebe da simples leitura dos títulos judiciais, e havendo, ademais, prova submetida ao contraditório judicial para sustentar o juízo condenatório, o debate relativo à suficiência do acervo probatório amealhado não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.

(AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)"

Observo, por oportuno, que a decisão proferida no HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021, foi anulada por decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.342.077, a qual assentou:

"(...) a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação, como se verifica nos itens 7.2, 12 e 13 da Ementa do referido julgado:

'7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. (...)

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência

do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.'

(...)

Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE

Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) (...)."

Com efeito, nada há nos autos a respaldar a tese de violação de domicílio, o que macularia as provas produzidas, razão pela qual afasto a respectiva tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo(a)(s) Sr(a)(s). Fabricio Rodrigues Dias Silva

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um

dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir)."

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como cocaína, definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão (fls. 14/15) e a prova oral produzida em juízo provam que estavam na posse do réu.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Neilvado Fernandes Junior, policial militar, narrou que: não conhecia o acusado. Receberam denúncia em seu desfavor, indicando que estaria promovendo tráfico de drogas em sua residência na Rua XV de Novembro, bairro Jardim Aeroporto. Em diligências, localizaram o indivíduo, saindo da residência indicada, decidiram abordá-lo, passando a entrevistá-lo. Durante a entrevista constataram que a pessoa abordada se tratava do acusado. O réu confessou que possuía certa quantia de substância entorpecente em sua residência. Alegou que estava promovendo tráfico por estar desempregado, bem como por não ter recebido auxílio do governo, além de por ter sofrido acidente. O réu franqueou a entrada em seu imóvel e indicou os locais onde estavam armazenados a droga. Foram localizadas

duas pedras da droga crack e duas balanças de precisão. Afirmar que o acusado poderia confeccionar, aproximadamente, trinta porções de entorpecente, utilizando-se de outras substância para fazer o "tombo" (mistura). Não receberam denúncia no dia dos fatos. Não acessaram o aparelho celular do réu. Não se recorda se foi apreendido aparelho celular. Reitera que não conhecia o réu e que apenas tinha conhecimento que na residência em que o referido morava havia denúncia de tráfico em desfavor de um indivíduo chamado Fabrício. O agente PM Oberdan participou da ocorrência. A confissão se deu perante aos dois agentes policiais. No momento da abordagem o réu estava sozinho.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Oberdan Coutinho Santos, policial militar, narrou que: estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Aeroporto. Afirmar que havia denúncia em desfavor do réu, indicando que estaria promovendo tráfico de drogas no bairro em um certo "cortiço". Conhece o acusado. Já o abordou em outra ocorrência. Em diligências, localizaram o acusado saindo de sua residência. Decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, foram encontrados apenas cinco reais. Em conversa, o réu confirmou que possuía drogas em sua residência e estava promovendo tráfico por estar desempregado, bem como por ter sofrido acidente. Foram até o imóvel do réu e, com a entrada franqueada pelo aludido, localizaram porções de droga, duas balanças de precisão e dinheiro (R\$ 700,00). As denúncias foram recebidas, aproximadamente, trinta dias antes dos fatos. Aduz que as denúncias eram dirigidas a sua equipe pelo fato de ser integrantes da Força Tática. O aparelho celular do réu foi apreendido, entretanto, não tiveram acesso ao seu conteúdo. No momento da abordagem o acusado estava sozinho.

Em juízo, a testemunha de defesa, a Sra. Isabela Gomes da Silva, ouvida como informante, narrou que: é esposa do réu. Tem conhecimento que o marido faz uso de maconha e já utilizou cocaína. No período dos fatos o réu estava afastado do emprego. Disse que o dinheiro apreendido era de sua titularidade e seria utilizado para pagar o aluguel (R\$ 650,00). Não havia circulação de pessoas em sua residência. A genitora do acusado presta auxílio com as despesas. Declara que guarda o dinheiro do aluguel em sua residência. Efetua os pagamentos mensais em espécie, sem comprovação por meio de recibo. Na época dos fatos estava trabalhando e fornecia dinheiro ao réu para fazer as compras. A genitora do acusado comprava alimentos para o sustento familiar. Nunca comprou droga para o marido. Nunca presenciou o réu fazendo uso de drogas. Não tinha conhecimento das balanças de precisão apreendidas.

Em seu interrogatório, o réu, o Sr. Fabrício Rodrigues Dias Silva, confirmou a titularidade do entorpecente, negando qualquer tipo de traficância. É usuário de maconha e cocaína. Comprou a balança para aferir a quantidade de droga adquirida. Em certas oportunidades comprovou que a quantidade não correspondia à adquirida, porém, nunca reclamou com o vendedor. Um das balanças estava danificada. Argumenta que o entorpecente era destinado a seu uso. Retirava pequenos pedaços de drogas para serem utilizados aos poucos. O entorpecente estava armazenado em um armário da cozinha. Sua esposa não tinha conhecimento de sua situação de usuário de cocaína. Nega que estivesse promovendo o tráfico de drogas. Pegou dinheiro escondido de sua esposa para comprar a droga. O dinheiro encontrado estava no quarto e pertencia a sua companheira. Não possuía maconha em sua residência. Declara que ao constatar que a quantidade de droga não correspondia a adquirida, deixava de comprar com o vendedor, buscando por outro. No dia dos fatos estava na residência da sua genitora. Durante o ocorrido estava em negociação para vender um carro. Pegou uma motocicleta emprestada e dirigiu-se até sua residência para tirar fotografia do veículo. Foi abordado ao sair de sua residência. Os agentes o indagavam: "onde está a droga". Foi obrigado a desbloquear o celular para que os agentes tivessem acesso ao conteúdo do aparelho. Asseverou que os policiais informaram que sua esposa também seria presa. Não autorizou o acesso a sua residência, apenas abriu a porta por medo de que sua companheira fosse detida. Nega que tenha confessado os fatos aos militares. Sua esposa estava trabalhando no momento do ocorrido. Já foi apreendido quando menor. Alega que uma das balanças estava danificada. Comprou a droga dias antes do ocorrido, possivelmente no dia 05/02/2021. Sua esposa recebia a título de vale o valor de R\$ 1.000,00. Pegou R\$ 200,00 para comprar o entorpecente.

Disse que sua esposa não percebeu a falta do dinheiro.

Os policiais em juízo, afirmaram que receberam denúncia anônima dando conta de que o réu estava traficando; ao localizá-lo em frente a sua casa, procederam à busca pessoal, mas nada encontraram. Sem embargo, o réu teria confessado a prática do crime e franqueado a entrada no imóvel, onde foi encontrada cocaína em estado bruto, para além de duas balanças.

A versão do réu não é crível. Sobre as balanças, disse que as tinha para verificar se não estava sendo passado para trás, na condição de usuário. Indagado pelo Ministério Público o que faria caso constatasse que havia sido enganado pelo traficante, não soube responder; apenas quando induzido pelo defensor, disse que "não voltaria a comprar do mesmo traficante".

Nem é crível que uma pessoa que receba um salário mínimo não perceba o sumiço de quase 20% da quantia ao longo de um final de semana.

Aliás, revela-se destituída de provas a versão de que o dinheiro encontrado seria destinado a pagar o aluguel. Com efeito, afirmou a informante que o pagamento é feito em espécie e não há emissão de recibo. Poderia a defesa ter chamado aos autos o locador para confirmar a frágil versão; mas não o fez. Validar, porém, essas alegações de fato, destituída de provas, não prospera.

Fato é que ao ser interrogado, a parte ré aduziu fatos que anulariam as provas obtidas e deu explicações que, a seu ver, teriam o condão de demonstrar que a droga destinava-se ao seu uso pessoal. Em suporte a seus relatos, não produziu qualquer prova.

Por isso, merece maior crédito a narrativa policial, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse na causa (não há razão para acusarem injustamente o réu). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policiais no momento da abordagem.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO.CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.
5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.
6. Ordem denegada.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Desta feita, reputo que os entorpecentes estavam na posse da parte ré. No caso, a quantidade e variedade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão (droga apreendida com duas balanças de precisão) e a forma de acondicionamento da droga (pedras em estado bruto com alto grau de pureza) demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico.

De mais a mais, é ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018). Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

“HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível

com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)”

Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Embora o réu tenha confessado o crime em sede policial, retratou-se em juízo, não fazendo jus à atenuante do art. 65, inc. IV, “d”, do CP, tanto mais quando sua confissão extrajudicial não foi utilizada para aferir a autoria (inteligência da Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”).

Dispõe o art. 33, §4º, da Lei

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017);

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

(iii) não é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC 184.979-AgR/SP, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 07/08/2020; REsp 1916596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

(iv) é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.14/05/2019, DJe 24/05/2019);

(v) diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito (HC 477280/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 458735/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 23/10/2018);

(vi) as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Repercussão Geral Tema 712). Assim, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem (AgRg no HC 497047/SP, Rel. Min. Rogério SCchietti Cruz, Sexta Turma, j.

14/05/2019, DJe 25/06/2019; HC 472052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(vii) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF (HC 510248/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 13/06/2019; HC 491328/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 01/07/2019);

(viii) reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistente óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; HC 482626/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2019, DJe 09/04/2019); e

(ix) o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600; AgRg no HC 485746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no HC 485237/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No presente caso, tem-se que o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes. Ademais, nada há nos autos a indicar que se dedique à atividade criminosa ou que integre organização criminosa. Em que pese a natureza deletéria da droga que trazia consigo, a quantidade é ínfima. Desta feita, faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3. Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o(a)(s) Sr(a)(s). Fabricio Rodrigues Dias Silva praticou(aram) o(s) delito(s) de Tráfico de Drogas, devendo

ser responsabilizado(s) penalmente pelas suas condutas.

III – FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de _Tráfico de Drogas praticado pelo(a) Sr(a). Fabrício Rodrigues Dias Silva

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), deve ser observado que a natureza da substância apreendida é altamente deletéria, ainda que a quantidade seja relativamente pouca. No mais, tem-se que:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumprido, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na

primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe. 21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 268/269) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 270/271) da parte ré, não se constata nenhuma condenação definitiva por infração praticada antes desta em julgamento. Assim, os antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos,

ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antisociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) Na análise do comportamento da vítima, deve-se examinar se a vítima contribuiu, de alguma maneira, para a produção do resultado.

O crime em questão é classificado